

1500067-27.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... requereu a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e condenação do acusado Gabriel em relação ao delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa dos acusados requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-27.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2003028/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22270719 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 43/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2003028 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 43/22/942 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2003028/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PAULINO MACIEL e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Gabriel Paulino Maciel e Tiago Lima da Silva, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, bem como em face de Gabriel Paulino Maciel, como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, em concurso material de crimes, também do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 14h00min, no estabelecimento prisional CPP Campinas "Professor Ataliba Nogueira", situado na

Rodovia SP-101, Km 45, Chácara Três Marias, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu Tiago trazia consigo, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros plásticos do tipo "filme" retorcidos, contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total de 25,8g (vinte e cinco gramas e oito decigramas), droga capaz de provocar dependência física ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu Gabriel trazia consigo, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) invólucros plásticos do tipo "filme" retorcido, contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total de 19,1g (dezenove gramas e um decigrama), droga capaz de provocar dependência física ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu Gabriel ingressou com 02 (dois) aparelhos telefônicos de comunicação móvel, tipo "micro celulares", e com 04 (quatro) chips da operadora TIM, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 07/09); auto de exibição e apreensão (págs. 10/11); laudo pericial preliminar (págs. 60/62 e págs. 63/65) e laudo pericial definitivo (págs. 110/112 e págs. 113/115).

Por decisão proferida em 21 de janeiro de 2022 (págs. 138/140), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (pág. 156), o que fizeram por meio da Defensoria Pública (págs. 160/161). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e condenação do acusado Gabriel em relação ao delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa dos acusados requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em relação ao artigo 349-A do Código Penal, pleiteou pela absolvição, tendo em vista que a prova se baseou somente na confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Vejamos.

A testemunha Vinicius da Silva Prazeres, agente penitenciário, em sede administrativa, declarou ser agente penitenciário no CPP Prof. Ataliba Nogueira, visto que, na data do fato, por volta das 14h00min, durante revista de presos, aos quais retornavam da saída temporária de Natal, ao submeter os acusados a scanner corporal, junto ao seu colega de farda, localizou, no interior do estômago do acusado Tiago, 10 invólucros com aparência semelhante a um "trouxinha" de droga, bem como também avistou, no interior do estômago do acusado Gabriel, 05 invólucros com aparência também semelhante a uma "trouxinha" de drogas, 02 micro celulares e 04 chips de celular. Questionados, ambos confessaram que haviam engolido os objetos, destinados a uso pessoal, visto que, logo em seguida, ingeriram água voluntariamente e expeliram todos os objetos pela boca, sendo conduzidos ao Hospital Mario Gatti, local em que permaneceram por observação e, posteriormente, receberam alta.

Em juízo, disse que no dia dos fatos estava recepcionando os presos que chegavam da saída temporária de Natal. Que durante o retorno ao presídio, os réus foram submetidos a revista através de scanner corporal, sendo possível localizar alguns objetos no estômago de ambos. Os réus disseram que engoliram maconha, mas que seria para uso próprio. Com um dos acusados também foi possível localizar aparelhos celulares.

A testemunha Oziris Rodrigues Barbosa, agente penitenciário, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que não se recorda dos fatos.

O acusado Tiago Lima da Silva, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, disse que estava em saída temporária. Ao retornar ao presídio, "arrumou" R\$ 100,00 reais e comprou 10 (dez) trouxinhas de maconha para uso próprio. Que é usuário "crônico" de maconha. Que estava preso por tráfico de drogas.

O acusado Gabriel Paulino Maciel, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, disse que engoliu 19 (dezenove) gramas de maconha e aparelhos celulares. Que estava há um ano preso e é usuário de maconha. Que conseguiu dinheiro com seus familiares e comprou entorpecentes para uso próprio. Os celulares seriam utilizados para conversar com seus familiares. Que é usuário de drogas desde os 14 anos de idade.

Em relação ao delito previsto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, de rigor a desclassificação para o artigo 28 da referida Lei. Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada por meio do auto de apreensão e exibição de págs. 10/11 e pelo laudo pericial definitivo (págs. 110/112 e págs. 113/115), o qual comprovou a natureza entorpecente do material encontrado em poder dos acusados, não há como se impor, a estes, o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei de Drogas).

Para formação da convicção condenatória, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal ou de traficância.

Ademais, com base no 28, § 2º da Lei de Drogas, observo que a quantidade apreendida com os réus não era expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio, bem há de considerar que os acusados aduziram que as drogas localizadas eram para uso próprio.

Ainda, em que pese a reincidência de Gabriel em relação ao crime de tráfico de drogas, a versão de que os entorpecentes se destinariam a consumo pessoal apresenta respaldo, dada sua pouca quantidade e natureza, e da inexistência de outros elementos a corroborar a traficância.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão das drogas em poder dos acusados; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva, fazendo-se, caso contrário, apenas uma pressuposição de traficância, como no caso.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e incontestada, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Em relação ao delito previsto no artigo 349-A do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado Gabriel ingressou com 02 (dois) aparelhos telefônicos de comunicação móvel, tipo "micro celulares", e com 04 (quatro) chips da operadora TIM, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Importante salientar que a conduta do acusado, prevista no artigo 349-A do Código Penal, amolda-se perfeitamente ao tipo penal supracitado, uma vez que tal prática delituosa necessita, eminentemente, de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise

minuciosa dos fatos.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Outrossim, ao contrário do que aduz a defesa, é certo que a confissão foi corroborada pelos demais elementos coligidos, a exemplo do depoimento dos agentes prisionais.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Dessa forma, considerando-se os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, bem como pela confissão do acusado, clara está a consumação do crime, ainda que o uso do aparelho se destinasse à comunicação privada com a família.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para os réus Gabriel Paulino Maciel e Tiago Lima da Silva:

Quanto ao artigo 28 da Lei n. 11.343/06:

Fixo a pena em prestação de serviços à comunidade, nos conformes do artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 05 (cinco) meses, para cada um dos acusados, tendo em vista o modus operandi ousado e elaborado, pela prática de delito em estabelecimento prisional e pela circunstância de ter o delito sido praticado durante o cumprimento de pena.

Inviável considera-los reincidentes para fins de extensão do prazo máximo para 10 (dez) meses, nos moldes do art. 28, § 4º, da Lei 11.343/06, na medida em que a reincidência tratada no mencionado dispositivo legal é a específica.

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido. (REsp 1771304/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 10/12/2019)

Para o réu Gabriel Paulino Maciel:

Quanto ao artigo 349-A do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. 0007334-

82.2016.8.26.0048 – págs. 75/76) do art. 61, I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, tratada no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR os acusados:

1)- TIAGO LIMA DA SILVA por violação ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução;

2)- GABRIEL PAULINO MACIEL por violação ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 349-A, do Código Penal.

Determino o regime aberto para início do cumprimento da pena do acusado Gabriel, pelo quantum de pena aplicado.

Para Gabriel, nos termos do artigo 44, §3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na frequência a curso ou tratamento pelo período de cumprimento de pena em local a ser indicado pelo Juízo da Execução.

Reconheço aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. No mais, em relação ao réu Gabriel, nos termos do artigo 319, IV do Código de Processo Penal, imponho a seguinte condição: proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege, na forma do art. 804 do Código Processual Penal.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA